

1500131-94.2021.8.26.0605

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael

Comarca: Andradina

Foro: Foro de Andradina

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 04/03/2022

... apreendido em flagrante por possível tráfico, mas concedida remissão. Nos processos 0002262-21.2018.8.26.0024, 0005920-87.2017.8.26.0024 e 1502261-25.2019.8.26.0024 ainda foi apreendido por porte de drogas para consumo pessoal. Por sua vez, o tráfico de drogas é crime de ação múltipla (tipo misto alternativo/conteúdo variável) e a prática de quaisquer dos verbos contidos no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Andradina

Foro de Andradina

3ª Vara

Rua Paes Leme, 2052, Andradina-SP - cep 16901-110

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500131-94.2021.8.26.0605 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500131-94.2021.8.26.0605

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2105094/2021 - DEL.SEC.ANDRADINA, 17393094 - DEL.SEC.ANDRADINA, 477/21/100 -

DEL.SEC.ANDRADINA, 2105094 - DEL.POL.MURUTINGA DO SUL, 477/21/100 -

DEL.POL.MURUTINGA DO SUL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE GUSTAVO BARBOSA DA CRUZ

O Ministério Público ofereceu denúncia contra FELIPE GUSTAVO BARBOSA DA CRUZ imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).

Narra a denúncia que no dia 16 de abril de 2021, por volta das 19h27min, na Estrada MGS-02, na altura do km 01, na cidade de Murutinga do Sul, nesta comarca de Andradina, o réu, qualificado às fls.10, 12/13, 25/26 e 39 dos presentes autos, transportava, para fins de tráfico, 01 porção de "maconha", com peso aproximado de 355,6g (cf. auto de constatação provisório de fls.36/38 e exame químicotoxicológico de fls.93/95), substância esta entorpecente e causadora de dependência física e psíquica, o fazendo sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida em 16 de novembro de 2021, em decisão de fls.166/167. O réu foi citado e apresentou resposta à acusação em fls.154/164.

Após regular instrução, o Ministério Público manifestou-se pela condenação, entendendo demonstradas a materialidade e autoria do delito imputado; a d. Defesa,

por sua vez, requereu a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal, absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, aplicação do redutor previsto no § 4º e consideração da confissão espontânea, além da substituição da pena e fixação de regime aberto.

É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO.

Inexistem nulidades ou irregularidades a serem sanadas. O feito tramitou regularmente. Não foram arguidas preliminares ou questões prejudiciais aptas a impedir o prosseguimento da marcha processual, razão pela qual passo à análise do mérito da lide.

Após detida análise das provas produzidas e sopesadas as alegações das partes, conclui-se pela procedência da acusação.

Com efeito, a ocorrência do delito foi demonstrada pelos elementos da investigação (APF de fls.01/02 e boletim de ocorrência de fls.03/05 , termo de depoimento de fls.06/10; autos de exibição e apreensão de fls.17/18, fotografia de fl.27; laudos periciais de fls.93/95), bem como pelo resultado da instrução em juízo.

A autoria também foi comprovada, pelos elementos já indicados, prisão em flagrante e pelos consistentes relatos das testemunhas.

A prova oral, produzida sob o crivo do contraditório, foi no seguinte sentido:

O policial militar Andeson Estigarriba São Miguel contou que receberam informação de que um Uno azul estaria com entorpecentes. Deparam-se com um veículo semelhante e abordaram. Quatro ocupantes – três adultos e uma criança. Fizeram a busca no acusado Felipe e localizaram R\$ 39,00. Em continuidade, na busca veicular, sob o banco do motorista, em uma sacola plástica, cerca de 350 gramas de maconha. Felipe falou que seria parte para venda, parte para consumo. Falou que teria pago R\$ 500,00 e pego em Andradina a droga. Salvo engano, o acusado teria passagens pela Vara da Infância e da Juventude. A informação que receberam provavelmente foi "informal", via COPOM ou diretamente à equipe.

Interrogado, o réu negou a traficância. Disse ser usuário de maconha, fumando de 5 a 8 cigarros por dia. Toda a droga era para seu consumo. Atualmente trabalha como servente de pedreiro em uma fazenda no Mato Grosso do Sul e, mesmo lá, chega a fumar 5 cigarros de maconha por dia. Pagou cerca de R\$ 500,00 pela droga e, à época, recebia R\$ 80,00 por diária de trabalho.

Na fase policial, ainda houve a oitiva do outro policial (fl. 07) que atendeu a ocorrência e de Gabriel Marques de Oliveira (fl. 08)

Com efeito, o art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06 diz que "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

Na hipótese tem-se a apreensão de mais de 350 gramas de maconha, quantidade deveras relevante, notadamente para os padrões da região e para a cidade de residência do réu – Guaraçaí, com cerca de 8.000 habitantes. Apenas a título de argumentação, anote-se que um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente (TJSP, ACr nº 0000152-73.2017.8.26.0286, Rel. Des. Damião Cogan, 5ª Câmara Criminal, j. 26/10/2017), o que leva à conclusão de que a quantidade apreendida seria suficiente para confecção de 350 a 700 cigarros do entorpecente.

Também deve ser sopesada a circunstância de ter sido a droga adquirida em local distinto da residência do réu, e por preço provavelmente elevado para sua condição social, que labora como servente de pedreiro sem registro em CTPS.

Com relação aos antecedentes, completada há pouco a maioridade, verifica-se a anotação de diversos feitos na esfera infracional. O réu já cumpriu duas execuções de medidas socioeducativas por tráfico de drogas (0000453-88.2021.8.26.0024, com aplicação de prestação de serviços à comunidade e 0007462-72.2019.8.26.0024, de liberdade assistida), referentes aos processos de conhecimento 1500171-

47.2019.8.26.0605 e 1500618-95.2020.8.26.0024. Além disso, no processo 1500097-90.2019.8.26.0605 foi novamente apreendido em flagrante por possível tráfico, mas concedida remissão. Nos processos 0002262-21.2018.8.26.0024, 0005920-87.2017.8.26.0024 e 1502261-25.2019.8.26.0024 ainda foi apreendido por porte de drogas para consumo pessoal.

Por sua vez, o tráfico de drogas é crime de ação múltipla (tipo misto alternativo/conteúdo variável) e a prática de quaisquer dos verbos contidos no artigo 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente (HC 332396/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria 5ª Turma, julgado em 23/02/2016, e AgRg no AREsp 397759/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, Julgado em 04/08/2015).

Outra questão a ser ponderada é que as posições de usuário de drogas e traficante não são excludentes entre si. Em outras palavras, mesmo que o réu seja efetivamente usuário de drogas isso não é impeditivo para o reconhecimento do delito de tráfico – o usuário pode muito bem também ser vendedor ou, ainda, o vendedor ser usuário. Corroborando tal raciocínio: “a alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade” (RJTJ 101/498).

Aliás, é comum que usuários adentrem ao mundo do tráfico justamente para sustentar o vício, por ser a atividade ilícita extremamente lucrativa.

Some-se a isso a confissão formal do acusado perante a autoridade policial, não convencendo a alegação de que fora coagido pelos policiais militares, vez que o interrogatório é prestado para policiais civis e para o delegado de polícia, momento no qual o autuado em flagrante poderia revelar qualquer tipo de coação sofrida.

Diante desse contexto probatório, não há dúvidas de que a imputação do delito de tráfico é procedente, pela expressiva quantidade de drogas, pela aquisição em cidade diversa da residência do réu, pelo recente histórico infracional por tráfico e também pela confissão formal.

E o testemunho dos policiais não deve ser desacreditado apenas pela sua condição funcional. Não demonstraram ser tendenciosos ou qualquer especial disposição para prejudicar o réu, devendo o seu testemunho ser valorado como qualquer outro. Esta é a jurisprudência já pacífica sobre a condição de testemunha dos policiais militares e outros agentes de segurança.

Impondo-se a condenação, resta a fixação da sanção correspondente.

Critérios para fixação da pena:

Antes de iniciar a fixação da pena propriamente dita, cabem alguns esclarecimentos sobre os critérios gerais a serem utilizados para a dosimetria, especialmente sobre a forma de cálculo das frações de aumento e diminuição. A base de cálculo será o intervalo entre a pena mínima e máxima do delito, e não a pena mínima.

Na primeira fase, na qual fixa-se a pena-base, existem oito circunstâncias judiciais passíveis de valoração. A pena sempre partirá do mínimo previsto e, a cada circunstância judicial desfavorável ao acusado, somar-se-á à reprimenda mínima cominada a fração de um oitavo (pois são oito circunstâncias), calculada pelo intervalo entre o máximo e o mínimo de pena previstos em lei para o crime em questão. A partir deste intervalo entre a pena máxima e a mínima encontra-se a fração respectiva de um oitavo para cada circunstância desfavorável.

Exemplificando-se, para melhor compreensão: se um crime tem pena mínima de 12 anos e máxima de 20 (como ocorre com o tipo previsto no art. 159, § 1º do Código Penal), o cálculo das frações é feito sobre o intervalo de 8 anos entre a pena mínima e máxima, e não sobre os 12 anos da pena mínima. A cada circunstância negativa considerada somar-se-á à pena mínima 1/8 sobre oito anos, o que representa um ano.

Se não houver circunstância negativa, a pena-base será a mínima, de 12 anos; ao contrário, se todas forem desfavoráveis, a pena parte do máximo legal, 20 anos.

Tal forma possibilita ao mesmo tempo: i) controle sobre os patamares utilizados pelo julgador, que se move em espaço conferido pelo legislador por meio de critério racional; ii) proporcionalidade, pois cada circunstância terá, em regra, peso semelhante e será calculada de acordo com os patamares mínimo e máximo da pena, abarcando de forma global a gravidade do crime; iii) fixação da pena partindo sempre do mínimo legal, com a possibilidade de se chegar ao máximo previsto, caso as oito circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis.

O critério também evita indesejáveis discrepâncias, como nos casos de crimes com pena mínima muito elevada ou diminuída. Se o cálculo partir da pena mínima, pode-se chegar a exasperações exageradas (como no caso da extorsão mediante sequestro

seguida de morte, cuja pena mínima é de 24 anos) ou ínfimas (neste caso nunca se chegando perto da pena máxima cominada para o delito, como no crime de ameaça). Ademais, permite que crimes que possuem a mesma pena mínima, mas diferentes penas máximas, justamente por serem de gravidade distinta (como a lesão corporal do caput e a figura do § 9º), sejam apenados adequadamente, cada um com sua gravidade e grau de censura já estipulados em lei. Seria injusto que para crimes de diferente gravidade a exasperação da pena-base partisse do mesmo patamar.

Via de regra, este será o critério utilizado na primeira fase. Diante da peculiaridade de cada caso as frações de cálculo poderão ser diminuídas ou aumentadas, para que se possa individualizar adequadamente a pena, de forma fundamentada (como por exemplo, nos casos de várias condenações criminais ou reincidência específica). O critério explicitado servirá sempre de parâmetro, porém não impedirá seja a pena-base fixada de modo diverso (para mais ou menos) se o caso assim recomendar (valendo isto também para a segunda fase).

Na segunda fase, na qual incidem agravantes e atenuantes, a fração usada para valoração será, no mais das vezes, de um sexto (1/6), calculado ou sobre o intervalo entre pena mínima e máxima, como acima, ou sobre a pena-base já fixada - o que for maior.

E utilizar-se-á o maior valor por uma razão simples: há uma hierarquia no sistema trifásico que deve ser respeitada. O sistema trifásico é escalonado, tendo cada fase maior relevância sobre a precedente. As circunstâncias do art. 59, valoradas pelo julgador, jamais podem preponderar sobre agravantes ou atenuantes, elevando a pena em patamar acima destas, que já foram estipuladas como mais graves de antemão pelo próprio legislador. A fração de 1/6 será utilizada pois é a menor prevista para as causas de diminuição e de aumento de pena e, com isso, respeita-se novamente a hierarquia do sistema trifásico.

Por fim, como não poderia deixar de ser, as causas de aumento ou de diminuição de pena incidirão sobre a reprimenda fixada provisoriamente na primeira e segunda fases, de forma sucessiva (incidindo umas sobre as outras, em cascata), segundo entendimento preponderante nos tribunais. Do contrário poderia se chegar ou a penas negativas, no caso de diversas causas de diminuição, ou na utilização de critérios distintos para causas de aumento e de diminuição, o que não é isonômico.

Friso que o critério ora explicitado vem sendo consagrado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (HC 498586 / SP - 5ª Turma - julgado em 11/02/2020), verbis:

"2. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

3. As agravantes não necessariamente incidem sobre o resultado da pena-base, cujo acréscimo de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa multiplica o intervalo de pena decorrente da diferença entre a pena mínima e máxima cominadas ao tipo, para então somar à pena mínima. Portanto, as agravantes incidirão sobre a pena-base se for maior ou igual ao intervalo de pena em abstrato do preceito secundário, caso contrário, malgrado haver pena concreta dosada, as agravantes serão fixadas com parâmetro na base de cálculo das circunstâncias judiciais, sob pena de as agravantes serem menos gravosas do que meras circunstâncias judiciais". E ainda (AgRg no REsp 1704633 / TO - 6ª Turma - julgado em 24/09/2019): "A divisão do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato pelas oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP é um, entre outros, dos critérios que podem ser utilizados na fixação da pena-base".

Dito isso, passo efetivamente a fixar a pena.

Na primeira fase, pelos parâmetros do art. 42 da Lei de Drogas, a quantidade da droga apreendida recomenda a exasperação da pena-base em 1/8, pelo critério de cálculo acima explicitado (encontro da fração a partir do intervalo entre a pena mínima e máxima do delito), notadamente pelas dimensões de Guaraçaí, conforme estabelecido na fundamentação. Nesse passo, estabeleço a pena-base em 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa.

Na segunda fase, observo que o acusado confessou o crime na fase policial, circunstância levada em conta para a formação da condenação sobre a condenação. Na esteira de já consolidada jurisprudência do STJ (HC n. 365.963/SP), incide a atenuante, conduzindo a pena novamente ao mínimo legal - 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase, inviável a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33, por conta da clara dedicação às atividades criminosas, uma vez que o acusado ostenta vasto histórico infracional por atos análogos a tráfico. Conforme já colocado, o réu já cumpriu duas execuções de medidas socioeducativas por tráfico de drogas (0000453-88.2021.8.26.0024 e 0007462-72.2019.8.26.0024), referentes aos processos de conhecimento 1500171-47.2019.8.26.0605 (fl. 230) e 1500618-95.2020.8.26.0024 (fl. 231). Além disso, no processo 1500097-90.2019.8.26.0605 (fl. 229) foi novamente apreendido em flagrante por possível tráfico, mas concedida remissão com aplicação de medidas.. Confira-se a jurisprudência a respeito:

"O histórico de ato infracional pode ser considerado para afastar a minorante do art. 33, § 4.º, da Lei nº 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal com o crime em apuração". STJ. 3ª Turma. EREsp 1.916.596-SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. Acd. Min. Laurita Vaz, julgado em 08/09/2021. No caso, a última condenação por tráfico (fl. 231) é de fevereiro de 2021, sendo o ato grave e recente, adequando-se a hipótese ao precedente supra indicado.

Neste ponto, anoto que para aplicação da causa de diminuição em questão não basta a primariedade ou quantidade de drogas não tão expressiva. É dizer: a relativa pequena apreensão ou a primariedade não conduzem automaticamente à aplicação do redutor. Caso esteja comprovado que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, mesmo primário, não receberá o benefício legal.

E a interpretação de que o redutor deve ser aplicado, sem maiores critérios, a todo réu primário ou ao "pequeno traficante", aquele que atua na ponta final do ciclo de distribuição da droga, o mero vendedor de varejo, também não é a mais adequada aos fins da Lei 11.343/06 e à própria Constituição (a qual deu tratamento bastante enfático e especial a este crime, o estabelecendo como um dos mais graves de nosso ordenamento - vide artigos 5º, XLIII e LI, 144, II e 243, parágrafo único).

Com efeito, caso o réu primário ou "pequeno traficante" dedique-se a atividades criminosas, ainda que de mera venda de pequenas porções cotidianamente, deve-lhe ser negada a aplicação do redutor. Em outros termos: o redutor somente é cabível àquele que pratica o tráfico de forma episódica, eventual, como um desvio em seu caminho e não como um padrão de vida, ainda que a conduta não se revista de gravidade comparável à das grandes organizações (para estas, a lei reservou pena de até 15 anos, a qual, aí sim, seria inaplicável para um simples vendedor de varejo). Sendo assim, a pena fica em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

O regime inicial, tendo em vista a gravidade do crime, quantidade de pena e primariedade deve ser o semiaberto. Pelas mesmas razões, inviável a substituição da pena, que não seria adequada à hipótese e nem possível pelo patamar de pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO FELIPE GUSTAVO BARBOSA DA CRUZ, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, calculados em seu mínimo legal.

Permito recurso em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas do processo em 100 UFESPs, com as ressalvas da gratuidade.

Com o trânsito em julgado: i) comunique-se ao IIRGD e ii) Justiça Eleitoral, iii) anote-se a condenação (art. 372 das NSCGJ) e iv) expeça-se guia de recolhimento. Caso tal providência já não tenha sido determinada, determino a destruição das drogas apreendidas.

Com relação aos bens apreendidos, tratando-se de objetos utilizados para a prática do crime de tráfico, determino seu perdimento à União (revertendo-se ao Funad), na forma do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República e art. 63 e seguintes da Lei 11.343/06, além do Recurso Extraordinário 638.491.

Publique-se. Intime-se na forma legal.
Andradina, 04 de março de 2022.

Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica)